

1. 들어가며

안녕하세요, 수험생 여러분,

디자인보호법 강사 정다운 변리사입니다.

무더위와 습한 날씨에도 불구하고 이틀 간 전력을 다해 시험에 임하시느라 정말 고생 많으셨습니다.

발표 전까지 참고가 되실 수 있도록 아래와 같이 60회 2차 디자인보호법 시험 총평을 말씀드립니다.

2. 60회 2차 디자인보호법 시험 총평

(1) 전체적인 난이도 및 주안점

- 선택과목 P/F 제도가 도입된 이후 최근 5년간의 기출 난이도와 대비했을 때, 올해 60회 시험은 전반적으로 “평이한” 정도의 난이도로 판단됩니다.
- 판례 문제가 많이 출제되었으며, 특히 판례의 사실관계를 사례로서 풀이하는 문제뿐만 아니라, 대법원 판례의 판결요지 자체를 일반론으로 단순 기재하는 문제가 혼합되어 출제되었습니다.
- 특유디자인이나 심사기준 예시를 직접적으로 출제한 문제는 없었습니다.
- 출제된 4문제 모두 디자인보호법의 기본 법리(법조문, 판례)를 잘 이해하고 있고, 판례에서 사용된 판결의 요지에 부합하도록 사안을 해결하는 연습을 많이 했던 수험생에게는 무난하게 느껴졌을 것으로 보입니다.
- 특히 올해 60회 시험의 경우 특허법 등 산업재산권법 전반에 공통적으로 적용되는 법리 및 판례의 태도에 관한 문제가 다수 포함되어, 평소 타 과목에 대한 준비가 잘 되어있었던 것도 시험을 용이하게 치르는데 도움이 되었을 것 같습니다.
- 기출문제의 경향으로 비추어볼 때, 올해 또한 불필요한 논점에 많은 시간을 투자하기 보다는 1) 기본에 충실한 이해 위주의 공부와 2) 판례에 대한 명확하고 상세한 이해가 바탕이 되어야 디자인보호법 과목을 잘 공략할 수 있을 것이라는 점이 입증되었습니다.
- 다음 시험을 준비하는 수험생 여러분께서도 이 점을 꼭 기억하시기 바라며, 올해 시험에 출제되지 않은 중요한 특유디자인, 심사기준 및 헤이그 제도에 대해서도 대비하시기를 당부 드립니다.

(2) 문제 1의 해설 및 분석내용

- [핵심 키워드] 디자인의 유사판단(기능적 형상 포함), 신규성, 선출원주의, 심판과 소송의 관계(제152조), 저촉관계(제95조), 후권리자 정당한 권원 부정 판례(상표법상)

- [설문 (1)]

- 디자인의 유사여부 판단 判例 : 디자인의 유사여부는 그 외관을 전체적으로 ~ (98후492)
- 기능적 형상 判例 ① 원칙 : 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 ~ (2003후1666)
② 예외 : 디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 ~ (2005후2274)
- 설문의 경우 : ‘오투기 형상’은 기능을 확보하는데 불가결한 부분은 아님. 따라서 유사판단 시 중요도를 낮게 평가할 수 없으므로 여전히 요부로 파악. A, B는 지배적인 특징이 유사한 ‘유사’한 디자인

- [설문 (2)]

- 신규성 무효사유 : 디자인 A의 등록에 따른 디자인공보 게재. 반포된 간행물에 게재된 디자인(33조1항2호)과 유사한 디자인(33조1항3호)
- 선출원주의 무효사유 : 선출원된 디자인 A와 유사한 디자인(제46조제1항)
- 신규성, 선출원주의 무효심판은 인용심결 예상

- [설문 (3)]

- 침해 여부를 판단할 수 있는지 : 소송 계속 중 심판청구에 따른 소송 중지여부. 법원의 재량(제152조제2항)이므로 무효심결확정 전이라도 침해소송 본안판단 가능.
- A에 대한 B의 침해로 판단할 수 있는지 : ① B의 등록이 적법하여 제95조 저촉관계 성립 시 甲의 허락 등 없이 실시하는 B의 행위 침해 성립 ② 다만, 본 사안은 신규성 위반도 되므로 B의 등록 부적법하여 제95조 적용 어려움. ③ 判例 - 후출원 등록된 권리자가 선권리자 동의 없이 실시하는 경우 선권리 침해 (2018다253444, 상표법상 판례). 따라서 무효심결확정 전이라도 침해 성립한다고 판단 가능.

(3) 문제 2의 해설 및 분석내용

- [핵심 키워드] 디자인의 유사판단(공지부분 포함), 색채의 취급, 배구공 판례

- [설문 (1)]

- 디자인의 유사여부 판단 判例 : 디자인의 유사여부는 그 외관을 전체적으로 ~ (98후492)
- 공지부분을 포함하는 경우 判例 ① 등록요건 판단 시 : 공지 형상을 구성요소로 하고 있는 등 그 부분이 ~ (2007후4830) ② 권리범위 판단 시 : 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고 ~ (2003후762)
- 설문의 경우 : 乙의 실시디자인과의 관계에서 문제이므로 권리범위 판단 시 취급 따름. 따라서 출원 전 공지된 부분의 중요도 낮게 평가, 양 디자인의 요부는 가슴부위 절개선. 지배적인 특징이 상이하므로 A, B는 서로 비유사한 디자인

- [설문 (2)]

- 형태의 구성요소에 따른 유사판단 방법 : ① 형상이나 모양 중 어느 하나가 유사 ~ ② 색채는 모양을 구성하지 않는 한 ~
- 채색 구도에 관한 판례의 태도 : 대비되는 두 디자인이 형상·모양이 동일하고 ~ (2005후3307)
- 설문의 경우 : 물품 동일, 형상 및 모양 동일, 기본적인 채색 구도 동일. 따라서 색채만 다른 디자인으로서 서로 유사한 디자인

(4) 문제 3의 해설 및 분석내용

- [핵심 키워드] 권리범위확인심판 확인의 이익, 무효의 항변, 자유실시디자인의 항변, 신규성 상실 예외 주장, 신규성 상실 예외 주장된 디자인에 관한 자유실시디자인 항변 가부 판례

- [설문 (1)]

- 권리범위확인심판 청구시기 : 등록디자인 유효 존속 중
- 소멸된 권리에 따른 심판의 확인의 이익 判例 : 일단 적법하게 발생한 디자인권이라 할지라도 ~ 확인을 구할 이익이 없어진다. (2019후10746)
- 설문의 경우 : 무효심결확정 시 디자인권 소급 소멸(121조3항). 심결 당시 사실관계에 따를 때 확인의 이익 없음.

- [설문 (2)]

- 무효의 항변 가부 문제 : 권리범위확인심판에서 무효의 항변 심리는 가능 (신규성)
- 창작비용이성 무효의 항변 判例 : 등록디자인이 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 ~ (2005후2922). 권리범위 부정 불가능

- [설문 (3)]

- 자유실시디자인의 항변 가부 문제 : 권리범위확인심판에서 자유실시디자인 항변 심리 가능
- 용이창작 자유실시디자인 항변 判例 ① 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 ~ 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 ~ (2016후878) ② ~ 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 ~ (2002후2037).
- 설문의 경우 : 자유실시디자인 항변 가능, 권리범위 속하지 않음

- [설문 (4)]

- 최근 대법원 判例 : 신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 공지디자인에 기초하여 자유 실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부. 소극 (2022후10012)
- 설문의 경우 : ① 신규성 위반 (출원-공지 디자인 동일) ② 신규성 상실 예외 주장 타당 (출원인 甲이 공지한 디자인) ③ 디자인 B가 A'와 유사범위일 때 자유실시영역에 속할 여지는 있으나, ④ 판례 따를 때, 乙의 A' 근거로 한 자유실시디자인 항변 허용되지 않음

(5) 문제 4의 해설 및 분석내용

- [핵심 키워드] 출원인 적격(제3조), 창작자의 승계인 판례, 공동출원, 공유물 분할 판례(특허법상)

- [설문 (1)]

- 제3조제1항 : 적법한 승계인도 디자인등록을 받을 수 있는 권리 있음. 따라서 창작자의 승계인 출원 시 등록 가능
- 창작자의 승계인 判例 : 디자인을 창작한 자가 아니라도 그로부터 ~ (2015후1669)
- 설문의 경우 : 乙의 단독출원은 무효사유 없음. 창작자 허위 기재도 무효사유 아님.

- [설문 (2)]

- 乙, 丙의 공동 창작으로 등록디자인 A가 유효 : 디자인등록을 받을 수 있는 권리 공유(제3조제2항), 공동출원(제39조)에 따른 디자인권 A 공유일 것
- 공유인 디자인권을 민법상 공유물분할청구에 의하여 분할 가능한지 判例 : ① 민법상의 규정 적용 ② 공유물분할청구에 관한 규정 적용 ③ 다만, 현물분할은 허용되지 않음 (2013다41578, 특허법상 판례)

3. 맺음말

시험을 준비하는 과정에서도 충분히 느끼셨겠지만, 모든 문제에 대해 시간 안에 주논점과 세 부논점까지 정확하게 추출해내어 답안을 작성한다는 것은 거의 불가능에 가까운 일입니다.

시험장에서 어느 때보다 더 긴장하고 집중해서 문제를 풀더라도 모두가 조금씩 부족하고 아쉬운 부분이 생기는 것은 당연합니다.

위 문제 해설은 저도 강사로서 충분한 고민을 하여 최대한 촘촘히 내용을 뽑아낸 것이므로 이와 같이 작성하지 못하였다고 선불리 좌절하거나 힘들어하지 않으셨으면 합니다.

제가 강의 때에도 늘 말씀드렸듯이, 기본적인 디자인보호법의 법리와 판례의 입장을 잘 이해

하고 설문에 녹여내려는 노력이 보이는 답안이라면 충분히 좋은 점수를 받고 이 과목에서 Pass를 기대하실 수 있을 것이라 감히 말씀드립니다.

당분간은 잠시 동안만이라도 지친 몸과 마음을 풀어주는 시간이 되시기를 바라면서, 저도 발표 때까지 많은 분들의 합격을 기원하고 있겠습니다.

감사합니다.

정다운 드림